

1502339-18.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... insuficiente para a reprovação de tráfico dessa monta. Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502339-18.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBERSON DOS SANTOS MARTINS

Data da Audiência:

12/01/2022

Réu Preso

Aos 12/01/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Davi de Castro Pereira Rio, foi aberta a audiência nos autos da ação acima referida. Presentes: a JUSTIÇA PÚBLICA, representada pelo ilustre Promotor de Justiça, Dr. Clóvis de Castro Humes, o acusado Cleberson dos Santos Martins e a Defensora Pública Dra. Rafaela Gasperazzo Barbosa. Iniciados os trabalhos, foram ouvidos os policiais Marcelo Pereira da Costa e Alexsander da Silva de Jesus, em separado. Após, o acusado foi interrogado. Dispensada a assinatura física dos depoimentos e interrogatório por se tratar de processo digital. As partes foram devidamente identificadas mediante apresentação de identidade funcional antes do início das gravações. Audiência realizada pelo sistema audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. Declaro encerrada a instrução processual, por não haver outras provas a serem produzidas". Em Alegações Finais dada a palavra ao Promotor de Justiça, manifestou-se por meio audiovisual. Dada a palavra a Defensora, assim se manifestou: "MM. Juiz, o réu CLEBERSON DOS SANTOS MARTINS está sendo processado pela suposta prática do delito descrito na denúncia. Contudo, a pretensão acusatória não merece prosperar, outra solução não havendo que a ABSOLVIÇÃO do réu, pelos motivos a seguir aduzidos: Verifica-se que a efetivamente incriminar o acusado consta nos autos exclusivamente as palavras dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu. O policial Marcelo afirmou em juízo que foi realizar operação no local, visando o combate ao tráfico de drogas, e o réu saiu correndo com um objeto na mão; foram ao encalço dele e se depararam com uma mulher, que

indicou um barraco (um aglomerado de madeira), onde o réu foi encontrado; o réu disse que não morava no local; em busca pessoal, foi encontrada quantia em dinheiro com o réu; em um armário quebrado, encontraram as drogas em uma sacola igual ao que o réu trazia; o réu permaneceu em silêncio. O depoimento do policial Alexsander foi no mesmo sentido. Todavia, bem se sabe que os policiais não são impedidos de prestar depoimento, nem se intenta simplesmente duvidar de suas palavras, no entanto, há de se atentar ao fato de que os policiais não têm condições de fornecer relatos capazes de sustentar um édito de rigor, já que tendem a produzi-los no sentido de validar a própria atividade. Assim, suas descrições dos fatos em juízo devem ser tomadas com cautela e, isoladamente, não podem ensejar a condenação do acusado. O réu, por sua vez, confessou a autoria do delito. Disse que estava há dois meses traficando no local. Contudo, a confissão não veio corroborada por outras provas idôneas. Ante a debilidade das provas colhidas pela acusação, não se pode afirmar com a certeza necessária ter sido o acusado responsável pela prática do delito de tráfico de entorpecentes e, portanto, requer-se a IMPROCEDÊNCIA da ação penal e, conseqüentemente, sua ABSOLVIÇÃO, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Caso não seja este o entendimento adotado, o que se admite por mera hipótese, requer subsidiariamente: 1) a aplicação da pena-base no patamar mínimo, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que deverá ser compensada com a agravante da reincidência; 2) o reconhecimento das circunstâncias previstas no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, para diminuir a pena em dois terços, haja vista estarem presentes os requisitos que autorizam a diminuição. A defesa entende que a reincidência, por si só, não obsta a aplicação do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº. 11.343/06. Com efeito, a negativa de aplicação da minorante apenas em função da reincidência importa ofensa aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. Se primário, ao réu seria possível a fixação de pena mínima no importe de um ano e oito meses de reclusão. Ao reincidente, entretanto, a pena mínima seria equivalente a cinco anos de reclusão. A desproporcionalidade das sanções, portanto, é evidente, especialmente se atentarmos para o fator de discriminação eleito, a saber, a reincidência. Isto porque a reincidência, nos demais crimes, importa, usualmente, em elevação da pena no montante de 1/6 (um sexto). Logo, não há razão para que no caso do tráfico de entorpecentes seja estabelecida uma diferença superior a 300% (trezentos por cento) entre primários e reincidentes. Além disso, a consideração da reincidência em dois momentos – no primeiro para elevar a reprimenda, no segundo para afastar a aplicação da causa de diminuição da pena – caracteriza a figura do bis in idem, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico. A mesma circunstância seria valorada duplamente na aplicação da pena, prejudicando o acusado na segunda e na terceira fases de fixação da reprimenda. Também não é o caso de considerar que o acusado se dedicava a atividades criminosas, pois a acusação não fez qualquer prova – testemunhal ou documental – nesse sentido; 3) a fixação, ao menos, de regime semiaberto para o cumprimento da pena; 4) a possibilidade de o réu apelar em liberdade, ante a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP". A seguir pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: VISTOS. CLEBERSON DOS SANTOS MARTINS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo relata a denúncia, no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 16hs20min, na Av. Dr. Álvaro de Campos Carneiro, Mogi das Cruzes/SP, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia, 221 (duzentos e vinte e um) invólucros contendo cocaína, 84 (oitenta e quatro) invólucros contendo Cannabis Sativa L e 96 (noventa e seis) invólucros contendo cocaína na forma de crack, substâncias entorpecentes listadas na Portaria nº 344/1998, SVS/MS, Lista F1 e F2 (Lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil). Recebida a denúncia (fls. 102/103), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta escrita à acusação às fls. 122. Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. DECIDO. A pretensão

punitiva estatal é procedente. A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 08/13, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pelo laudo de constatação provisória de fls. 23/26, pelo laudo pericial de fls. 140/143, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 144/146, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo. A autoria do delito é incontroversa. O acusado admitiu integralmente a prática do delito a ele imputado, informando que realizava tráfico de drogas no local havia dois meses. De fato, a confissão por ele apresentada está em plena consonância com as demais provas dos autos. Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado foram ouvidos em Juízo. O policial Marcelo Pereira da Costa contou que estava em patrulhamento de rotina, nas proximidades de local notoriamente conhecido pela alta incidência de tráfico de drogas, quando avistou o acusado em atitude suspeita. Disse que o acusado trazia em suas mãos um objeto e ele, ao avistar a presença de policiais, saiu correndo, mas acabou sendo detido. Contou que o acusado foi detido dentro de um imóvel, tendo sido localizado em seu poder dinheiro e, dentro de um armário, uma sacola, igual a que ele trazia consigo, e dentro dela diversos entorpecentes. No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Alexsander da Silva de Jesus. Deveras, nada desautoriza o depoimento prestado pelos policiais no caso concreto. Ao contrário, as testemunhas, ouvidas em juízo e na fase extraprocessual, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos. Destaco, ademais, que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário. Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander: "Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito." (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander) In casu, as provas produzidas em Juízo são firmes e seguras ao apontar o acusado como sendo autor do delito de tráfico de drogas, tendo ele próprio admitido tal fato. Dessa forma, provadas a autoria e a materialidade do delito, a condenação do acusado é medida de rigor. Passo, então, à fixação da pena. Passo, então, à fixação da pena. Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, o qual indica todos os parâmetros para a fixação da pena-base, levando-se em conta as circunstâncias do crime,

em especial a variedade e a nocividade da droga apreendida (crack) - cujos danos causados à saúde dos usuários são extremamente graves - , fixo a pena-base aumentada em um sexto, vale dizer, pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. No caso vertente, o aumento da pena-base justifica-se à luz da nocividade dos entorpecentes comercializados pelo acusado, os quais possuem alto grau de lesividade e dependência aos seus usuários. Sobre o tema, colaciono parte do acórdão da lavra do i. Des. Pinheiro Franco: "O crack (subproduto da cocaína), não se olvide, é estupefaciente altamente viciante e vem causando grande preocupação na sociedade, em razão da proliferação de seu uso. O viciado em crack, na maioria das vezes, acaba deixando a família, perde o emprego e bens, passando a viver nas ruas e enveredando, muitas vezes, para a senda do crime, de modo a sustentar sua severa condição de dependência química. Aquele que traz consigo, com vistas ao fornecimento ao consumo de terceiros, vinte e oito porções de entorpecente de tal natureza capaz de causar dependência quase imediata -, possui personalidade deturpada e conduta social altamente reprovável, devendo ser punido com mais rigor ainda, em homenagem ao binômio reprovação-prevenção." (Apelação nº 0015447-

27.2014.8.26.0361 - 73ª. Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo) Na segunda fase de fixação da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 68/70 – autos nº 0007056-71.2014.8.26.0462), bem como a circunstância atenuante da confissão espontânea, de forma que compenso ambas as circunstâncias e mantenho inalterada a pena. Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico a impossibilidade de seu reconhecimento, tendo em vista que o acusado é reincidente na prática de crimes dolosos, conforme retromencionado. Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. Ressalto que não há qualquer inconstitucionalidade no tipo legal do tráfico, ou mesmo em seu preceito secundário, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece um maior rigor contra os crimes hediondos e aos equiparados a estes. Tratando-se de crime equiparado a hediondo, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, sendo o regime fechado o único compatível para atender as finalidades de prevenção e repressão da pena. Neste ponto, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra o i. Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan (Apelação nº 0014063-92.2015 – 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo): “O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente. Outro regime seria insuficiente para a reprovação de tráfico dessa monta. Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, sendo exemplo disso que 70% dos processos em julgamento nas sessões ordinárias dessa E. Câmara, sempre em número superior a 500 feitos, são referentes a tráfico de drogas. Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios.” Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força do art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo fato de que não estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP. Indefiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, preso em flagrante delito, permanecem as circunstâncias que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar. Ademais, não há elementos para formar a convicção de que atenderia ao futuro chamado judicial se fosse, agora, colocado em liberdade, mormente após a condenação. Destarte, a manutenção da custódia faz-se necessária para aplicação da lei penal e assegurar a manutenção da ordem pública, que ficaria visivelmente abalada caso fosse colocado em liberdade. Ressalto que estão presentes todas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado às fls. 76/79. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar CLEBERSON DOS SANTOS MARTINS como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática delituosa. Indefiro o recurso em liberdade, ante as razões expostas. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Destaco ser incabível o reconhecimento da detração penal, uma vez que se trata de matéria afeta à execução criminal, sede natural para análise dos requisitos exigidos pela lei. Por fim, determino o perdimento da quantia e objetos apreendidos em poder do acusado em favor da União. Custas na forma da lei. Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados”. Pelo réu e por sua defensora foi dito que não há interesse em recorrer. Certifique-se o trânsito em julgado. Presentes todos em

audiência, dispensada assinatura física por se tratar de processo digital, nos termos dos artigos 1192, § 1º, e 1194, da NSCGJ. Nada Mais. Eu, (Roberta Chacon Oliveira Sterse), escrevente, digitei.